

DERECHO CONSTITUCIONAL

WALTER F. CARNOTA
PATRICIO A. MARANIELLO

LA LEY

INDICE GENERAL

Pág.

PARTE PRIMERA TEORÍA CONSTITUCIONAL

CAPITULO 1.1

INTRODUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL

1. Introducción 2
2. Situaciones previas al constitucionalismo 3
3. Derecho Constitucional: origen y desarrollo 11

CAPITULO 1.2

OBJETO, FUENTES Y MÉTODO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL. RELACIÓN CON OTRAS DISCIPLINAS

1. Introito 2
2. Perfiles del objeto del derecho constitucional 3
3. El sistema de fuentes del derecho constitucional 4
 - a) Las fuentes. Clasificación 4
 - b) La Constitución, los tratados constitucionales y las leyes constitucionales 5
 - c) El derecho judicial o jurisprudencia de los tribunales 6
 - d) La costumbre constitucional 7
4. Concepto de Constitución 8
5. Clasificación de constituciones 9
 - a) Constitución formal o material 9
 - b) Constitución rígida o flexible 10
 - c) Constitución originaria o derivada 10
 - d) Constitución monárquica o republicana 10
 - e) Constituciones normativas, nominales y semánticas 11

	Pág.
6. Tipos de constituciones	15
7. Clasificación de las normas constitucionales	15
8. Metodología del derecho constitucional	16
a) El método	16
b) Técnica	17
b.1) Técnicas cuantitativas y cualitativas	17
b.2) Técnicas de elaboración y de interpretación	18
c) Enfoques	19
9. Relaciones con otras disciplinas	19
a) Con la ciencia política	19
b) Con otras ciencias de la conducta (sociología, psicología social, antropología)	19
c) Con la economía	20
d) Con la historia	20

CAPITULO II.1

LA ENSEÑANZA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES COMO PARTE DEL DERECHO CONSTITUCIONAL

1. Introducción	23
2. Proceso de sedimentación	24
3. Nuevos retos	26
4. Más desafíos	28
5. Conclusiones	28

CAPITULO II. 2

LA INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN COMO PROBLEMA

1. Introducción	31
2. Interpretar la Constitución e interpretar la ley	31
3. Interpretar y controlar la Constitución	33
4. El lenguaje constitucional: textura abierta, vaguedad y ambigüedad	34
5. Modelos de interpretación constitucional	35
a) Interpretación literal o semántica	35
b) Interpretación sistemática	35
c) Interpretación historicista	36
d) Interpretación dinámica	36
e) Interpretación teleológica o finalista	36
f) Interpretación previsora	37

	Pág.
6. La interpretación comparada, ¿es de utilidad?	37
7. Rumbos de la tratadística constitucional	38

CAPITULO III

SUPREMACÍA Y CONTROL CONSTITUCIONAL

I. Supremacía Constitucional	39
1. Génesis del concepto	39
2. La supremacía en el derecho constitucional comparado	40
3. Significado e implicaciones del concepto de supremacía constitucional: su vinculación con la teoría de la fuerza normativa de la Constitución	41
4. La supremacía en la Constitución Nacional	42
a) Relación entre el derecho constitucional y el derecho internacional	42
b) Relación entre la ley interna y el tratado internacional	43
b.1) El caso "Ekmejdjian c. Sofovich": Trabajo práctico	43
b.2) El impacto de la reforma constitucional de 1994	44
II. El Control de Constitucionalidad	44
1. Orígenes del control de constitucionalidad	44
2. "Marbury v. Madison": La Corte empieza a ser Suprema	44
3. Enfoque práctico del caso	44
4. Los grandes sistemas del control de constitucionalidad en el derecho comparado. La jurisdicción constitucional específica	44
5. El control de constitucionalidad a nivel federal en Argentina	5
6. Problemas de teoría constitucional que arroja el control judicial: ¿hay una "dificultad contramayoritaria"?	5
7. ¿Nulidad o declaración de inconstitucionalidad de la reforma constitucional? Jurisprudencia: El caso "Fayt"	5

CAPITULO IV

CONTROL DE OFICIO DE CONSTITUCIONALIDAD

1. Introducción. Su marco científico	5
2. Caracteres generales	5
3. Análisis evolutivo en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Diferentes períodos o etapas	6
a) Período de necesidad justificatoria. Desde la instalación del Tribunal hasta 1941	6
b) Período negatorio con excepciones. Desde 1941 a 1984. Caso: "Ganadera Los Lagos S.A."	6

	Pág.
c) Período permisivo minoritario. Desde el año 1984 al 2001. Voto de los doctores Fayt y Belluscio en la causa "Inhibitoria planteada por el juzgado de instrucción militar N° 50" y "Peyrú, Osvaldo J. s /apelación"	61
d) Período permisivo mayoritario. Desde 2001 hasta la actualidad	63
d.1) Caso "Mill de Pereyra, Rita Aurora; Otero, Raúl y Pisarelo Angel c. Estado de la Provincia de Corrientes/ demanda contenciosoadministrativa"	63
d.2) "Banco Comercial de Finanzas S.A. (en liquidación Banco Central de la República Argentina) s/ quiebra" del 19 de agosto de 2004, Fallos: 327:3117.	65
4. Declaración de oficio. Recapitulación	66

PARTE SEGUNDA DINÁMICA CONSTITUCIONAL

CAPITULO I REFORMA CONSTITUCIONAL

1. Introducción	73
2. Las clases del poder constituyente	74
a) Poder constituyente originario	74
b) Poder constituyente derivado	75
c) Contenidos pétreos	75
d) Poderes constituidos	75
3. Titularidad del poder constituyente. Ejercicio	76
4. De nuevo sobre los límites	76
5. Procedimiento	76
6. Las reformas de la Constitución Nacional	77
a) La llamada reforma de 1860	77
b) La reforma de 1866	78
c) La reforma de 1898	78
d) La reforma de 1957	78
e) La reforma de 1994	78
f) Quid de una nueva reforma futura	78

CAPITULO II EMERGENCIA ECONÓMICA

1. Introducción	81
2. Deslindes conceptuales	82

	Pág.
3. La Constitución como instrumento permanente	82
4. El caso "Massa"	83
5. Conclusión: el círculo vicioso de la emergencia	84

PARTE TERCERA PRINCIPIOS, DERECHOS Y CLÁUSULAS CONSTITUCIONALES

CAPITULO I

LA EFECTIVIDAD Y OPERATIVIDAD DE LOS DERECHOS

1. Preliminar	87
2. Dominio de la ley o de los derechos fundamentales	8
3. Reglamentaciones e interpretaciones fieles	88
4. La declaración de derechos es en principio operativa	88
5. La fuerza normativa de la Constitución	89

CAPITULO II

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

1. Introducción	91
2. Los derechos de primera generación	91
3. Los derechos de "segunda generación"	92
4. Los derechos de "tercera generación"	93
5. Los derechos sociales sustentables como de cuarta generación	93
6. Conclusiones	94

CAPITULO III DERECHO AMBIENTAL

1. Introducción	95
2. Regulación normativa	96
a) Antecedentes. Conferencias y tratados internacionales	96
b) Antecedentes provinciales	100
c) Otros antecedentes constitucionales	101
c.1) Constituciones de la posguerra	101
c.2) Las constituciones mediterráneas de la década de los 70 ..	106
d) El art. 41 de la Constitución Nacional	10

	Pág.
d) Las primeras leyes en el derecho comparado	107
e) Leyes nacionales y/o provinciales	108
3. Jurisprudencia nacional y/o provincial	111
a) Casos relevantes anteriores a la reforma constitucional	111
b) Casos posteriores a la reforma constitucional	112
4. Protección administrativa y judicial del entorno	113
5. Desarrollo sustentable	114
6. La audiencia pública como medio probatorio en los derechos de incidencia colectiva	116
a) A modo de introducción	116
b) La garantía de ser oído y la audiencia pública	116
c) El marco constitucional y legal	117
d) La esfera reglamentaria	118
e) Proyección jurisprudencial	119
f) Su extensión al ámbito jurisdiccional	121
g) Beneficios que encuentra la doctrina en las audiencias públicas	122
h) Recapitulaciones	123
7. Los Tribunales Judiciales Ambientales en la Ciudad de Buenos Aires	124
a) Introducción	124
b) Situación en el derecho comparado	125
b.1) Guatemala	125
b.2) Honduras	125
b.3) Costa Rica	126
b.4) Panamá	126
b.5) Brasil	127
b.6) España	127
c) Opinión de la doctrina especializada	127
d) Proyecto en la Ciudad de Buenos Aires	128
d.1) Principio de gratuidad	129
d.2) Impulso de oficio	129
e) Conclusión	129

CAPITULO IV

EL PRINCIPIO DE IGUALDAD

1. Preliminar	133
2. Concepto y características	134
3. Regulación normativa	135
a) Constitución Nacional	135

	Pág.
b) Tratados internacionales	136
c) Legislación	138
4. Igualdad formal versus igualdad real o material. La no discriminación	139
5. Igualdad ante el Estado y ante los demás particulares	140
6. Las medidas de acción positiva como derivación de la igualdad real	140
7. Discriminación inversa	141

CAPITULO V

EL PRINCIPIO DE RESERVA, LEGALIDAD
Y RAZONABILIDAD

1. Introducción	143
2. El debido proceso legal: "due process of law"	144
3. Principio de reserva	145
4. Principio de legalidad	146
a) Génesis y desarrollo	146
b) Regulación normativa	148
c) Conflicto con normativas internacionales	148
5. Principio de razonabilidad	149
a) Concepto y características	149
b) Clases o tipos de razonabilidad	150
b.1) Razonabilidad interna de la ley	150
b.2) Razonabilidad externa de la ley	151
c) Jurisprudencia	151
c.1) Corte Suprema de Justicia de EE.UU.	151
c.2) Tribunal Constitucional Federal alemán	152
c.3) Corte Suprema de Justicia de Argentina	153
d) El principio de razonabilidad en la Constitución Nacional	154
d.1) Constitución histórica de 1853-60	154
d.2) Reforma constitucional de 1994	154
e) Tratados internacionales con jerarquía constitucional	155
e.1) Declaración Universal de Derechos Humanos	155
e.2) Convención Americana sobre Derechos Humanos o "Pacto de San José de Costa Rica"	155
e.3) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos	156
e.4) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales	156
f) Ingerencia de los tratados internacionales	157
g) Recapitulación del principio de razonabilidad	158

CAPITULO VI

LAS CLÁUSULAS DE BIENESTAR GENERAL

	Pág.
1. Introducción	161
2. Cláusula del bienestar general	162
3. Cláusulas del comercio	162
a) Antecedentes en el Derecho Norteamericano	162
b) Regulación en el Derecho nacional	164
4. Cláusulas de progreso o prosperidad	165
a) Antecedentes históricos	165
b) Constitución histórica de 1853-1860	166
c) Reforma constitucional de 1994 y el fortalecimiento del constitucionalismo social	166
d) Tratados internacionales con jerarquía constitucional	167
5. Cláusula del desarrollo humano	168
6. A modo de conclusión	169

PARTE CUARTA
ORGANIZACIÓN DEL PODER

CAPITULO I.1
PODER LEGISLATIVO

1. Introducción	173
2. Antecedentes	174
3. Conceptualización	174
4. Caracterización nacional	175
5. Composición del Congreso nacional	175
6. Funciones del Congreso	176
7. Formación y sanción de las leyes	177
8. Juicio político	178
9. Poderes expresos de legislación general	179
a) Económicos, financieros	179
b) Relaciones exteriores	180
c) Política cultural, inmigratoria y demográfica	181
d) Cláusulas del progreso	182
e) Cláusula comercial	183
f) Defensa	183

g) Ley de Presupuesto	184
10. Atribuciones especiales: leyes constitucionales	184
11. Poderes implícitos	185

CAPITULO I.2

RESPONSABILIDAD DE LOS ASESORES TÉCNICOS
EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN
DE NORMAS LEGALES

1. Introducción	187
2. Responsabilidad	192
a) Concepto y características	192
b) Clases o tipos de responsabilidad	193
c) Kelsen y su punto de vista desde la teoría general del derecho	193
3. Distinción entre responsabilidad y obligación	194
4. Responsabilidad de los funcionarios públicos	195
a) Antecedentes en el derecho comparado	195
a.1) Derecho francés	195
a.2) Derecho alemán	196
a.3) Derecho español	196
a.4) Reino Unido	197
a.5) República Bolivariana de Venezuela	198
b) Derecho argentino	198
b.1) Responsabilidad por error judicial	198
b.2) Actos normativos: Evolución jurisprudencial	199
b.3) Recepción jurisprudencial por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del caso "Bustos". Voto del Dr. Zaffaroni	199
c) Tipicidad en el derecho penal	200
5. A modo de conclusión	200

CAPITULO I.3

EL DEFENSOR DEL PUEBLO (OMBUDSMAN)

1. Introducción	203
2. Antecedentes históricos	204
3. Derecho comparado	205
a) Suecia	205
b) Finlandia	206

	Pág.
c) Dinamarca	206
d) Estados Unidos	206
e) Gran Bretaña	207
f) Francia	207
g) Italia	207
h) España	207
4. Regulación nacional y provincial	208
a) Ley 24.284 modificada por ley 24.379	209
b) Constitución Nacional	210
5. Atribuciones y funciones	210
6. ¿Cómo iniciar una queja?	211
7. ¿Constituye verdaderamente la voz del pueblo?	213
8. Competencia y legitimación	214
9. Responsabilidad	216
10. Conclusiones	219

CAPITULO II.1 EL PODER EJECUTIVO

1. Naturaleza unipersonal del órgano	221
2. Su dinámica operativa	222
a) Introducción	222
b) Elección	222
c) Funciones	223
d) Las jefaturas presidenciales	224
3. Atribuciones del Poder Ejecutivo	225
a) Las relaciones internacionales	225
b) El poder reglamentario	226
c) Participación en el proceso legislativo	226
d) Poder de nombramiento	227
e) Indulto y conmutación de penas	227
f) Poderes militares	228
4. Cese y acefalía	228

CAPITULO II.2 JEFE DE GABINETE

1. Introducción	229
2. Antecedentes	229

	Pág.
3. Atribuciones del Jefe de Gabinete de Ministros	230
4. Atribuciones y funciones dadas por la Ley de Ministerios	233
5. Diferentes corrientes doctrinarias	235
a) Acercamiento a la figura del primer ministro	235
b) Atenuación del presidencialismo	237
6. Administración y gobierno	237
7. Diferentes tesis funcionales	241
a) Tesis de la relación-supervisión	241
b) Tesis de la relación-jerárquica	241
8. A modo de reflexión	242

CAPITULO II.3 LOS DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA

1. Introducción	243
2. Concepto y características	245
3. Análisis jurisprudencial	247
a) Caso "Peralta"	247
b) Caso: "Video Club Dreams"	248
c) Caso: "Rodríguez Jorge" (Fallos: 320:2851)	249
d) Caso "Verrocchi" (Fallos: 322:1276)	251
e) Comparación entre el Caso "Rodríguez" y "Verrocchi": diferen- tes criterios del control o intervención del Poder Judicial sobre los decretos de necesidad y urgencia	253
f) Caso: "Risolfá de Ocampo María José c. Rojas Julio Cesar s/eje- cución de sentencia"	255
g) Jurisprudencia posterior	257
4. Revisibilidad de los Decretos de Necesidad y Urgencia	257
5. Comisión Bicameral Permanente	258
6. Actitud del Poder Legislativo en los DNU	261
7. Recapitulación	264

CAPITULO II.4 LA PROMULGACIÓN PARCIAL DE NORMAS Y EL VETO PARCIAL

1. Introducción	267
2. Veto parcial	269
3. Promulgación parcial de leyes	270

	Pág.
a) Concepto y clases	270
b) Organos de control	271
4. Comisión Bicameral Permanente	273
5. Evolución jurisprudencial	274
6. Comentario al fallo "Famyl S.A." (29/8/2000)	275
a) Antecedentes fácticos y jurídicos	275
b) Pretensión de la parte actora	276
c) Objeciones planteadas por la accionada	277
d) Voto de la mayoría	278
e) Glosa doctrinaria	281
7. Recapitulación	285

CAPITULO II.5

DELEGACIÓN LEGISLATIVA

1. Introducción	287
2. Naturaleza jurídica	288
3. Concepto y evolución	288
4. Los cambios en el sistema político	289
5. Reforma constitucional de 1994	291
6. El control parlamentario	293
7. Precisiones acerca de los criterios jurisprudenciales empleados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre delegación legislativa	294
8. Recapitulación	297

CAPITULO III.1

EL PODER JUDICIAL FEDERAL
DENTRO DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

1. Introducción	299
2. Tradición norteamericana y condimentación europea	299
3. Una Corte Suprema	300
4. Lo federal y lo local	301
5. Esquema organizativo del Poder Judicial nacional	301
a) Tribunales Federales con asiento en Capital Federal	302
b) Tribunales Federales con asiento en el interior del país	303
6. Organización del Poder Judicial de las provincias	304

	Pág.
7. Organización esquemática del Ministerio Público Nacional	305
8. Ejercicio de la abogacía	305
9. Lo internacional en el campo de los derechos humanos	305
10. Del derecho de defensa a la tutela judicial efectiva	306
11. Poder Judicial y participación ciudadana	306
12. Los procedimientos	306

CAPITULO III.2

EL ROL DEL JUEZ. POTESTADES Y LIMITACIONES

1. Planteo del tema	309
2. El rol del juez	310
3. Nuevas realidades. Funciones y Constitución Nacional	310
4. Valoración de las tareas de los jueces	311
5. Sus potestades y sus limitaciones	312
a) Las potestades del juez	312
b) Limitaciones del juez en la voluntad del pueblo	314
6. Responsabilidad en la decisión	314
7. Limitaciones al control de constitucionalidad a través de los fallos de la CSJN	314
a) Análisis de la Constitución Nacional	315
b) Criterios generales de la Corte Suprema de Justicia	316
8. Límites específicos del control	316
a) Clara individualización al caso concreto	317
b) Contradicción manifiesta e inconciliable con la Constitución Nacional	317
c) Irrazonabilidad evidente	317
d) Sólidos fundamentos y desarrollo argumentales	318
e) Estricta necesidad	318
9. A modo de conclusión	318

PARTE QUINTA

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

CAPITULO I

ALGUNAS PRECISIONES SOBRE LOS TIPOS DE DEMOCRACIA
(DIRECTA, SEMIDIRECTA E INDIRECTA) Y LA CONSULTA POPULAR

1. Introducción	323
-----------------------	-----

	Pág.
2. Antecedentes históricos	324
3. Antecedentes históricos en la Argentina	326
4. Derecho comparado	327
5. Derecho suizo	327
6. Formas directas en los actuales sistemas democráticos	328
7. Formas semidirectas explícitas	329
a) Referéndum	330
b) Trámite parlamentario	331
c) Plebiscito	332
8. Formas semidirectas implícitas o posibles	333
9. Las consultas populares en la Argentina	334
10. La regulación en la Constitución Nacional argentina, luego de la reforma de 1994	335
11. Análisis de la jurisprudencia argentina	336
a) Fallo de la Corte Suprema de Justicia: "Baeza, Aníbal R. c. Gobierno Nacional s/ amparo", del 28 de agosto de 1984	336
a.1) Derecho	336
a.2) Antecedentes legislativos	336
a.3) Precedentes jurisprudenciales	336
a.4) Jurisprudencia comparada	337
a.5) Objeto	337
a.6) Elementos fácticos	337
a.7) Primera y segunda instancia	337
a.8) Resolución de la Corte Suprema	337
a.9) Voto en disidencia del Dr. Carlos Fayt	339
a.10) Voto en disidencia del Dr. Augusto Belluscio	339
a.11) Comentario al fallo	340
b) Fallo de la Cámara Nacional Electoral, en los autos: "Fonrouge, Alberto s/ amparo", 28 de agosto de 1984	341
b.1) Derecho	341
b.2) Jurisprudencia	341
b.3) Objeto	341
b.4) Elementos fácticos	341
b.5) Fallo de primera instancia	342
b.6) Dictamen del Fiscal Federal de Río Gallegos	342
b.7) Dictamen del Procurador Fiscal Federal	342
b.8) Resolución de la Cámara Nacional Electoral	343
b.9) Comentario	344
12. Legislación argentina	344
13. Conclusiones	346

PARTE SEXTA

FORMAS DE ESTADOS

CAPITULO I

LAS FORMAS DE ESTADO Y LAS FORMAS DE GOBIERNO

	Pág.
1. Introducción	353
2. Formas de gobierno	354
a) Introducción histórica a las formas de gobierno	354
b) Clasificaciones contemporáneas	355
c) Las formas de la democracia constitucional	356
d) Parlamentarismo	357
e) Presidencialismo	358
f) El semi-presidencialismo	360
g) Hiper-presidencialismo	360
3. Formas de Estado	361
a) Introducción	361
b) La democracia, ¿forma de Estado o de gobierno?	361
c) El federalismo	362
c.1) Nociones	362
c.2) Principios que lo informan	363
c.3) El federalismo argentino comparado con el de los Estados Unidos	363

PARTE SÉPTIMA

DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

CAPITULO I

EL HABEAS DATA EN EL MUNDO INFORMÁTICO (SU AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL Y PROCESAL)

	Pág.
1. Introducción	367
2. Relevancia del tema	368
3. Regulación nacional y provincial	369
4. Interpretación en el sistema de la Convención Americana de Derechos Humanos	370
5. Definición conceptual	371
6. Derechos protegidos	371
7. Objetivos y subtipos	372

	Pág.
8. Procedimiento	372
a) Carril procesal	372
b) Legitimados	373
c) Competencia	374
9. Conclusiones	374

CAPITULO II

EL HABEAS CORPUS. SU EVOLUCIÓN
CONSTITUCIONAL Y JURISPRUDENCIAL

1. Introducción	377
2. Evolución histórica	378
a) Derecho romano	378
b) Derecho español	379
c) Derecho anglosajón	379
c.1) Reino Unido	379
c.2) Estados Unidos de América	380
3. El habeas corpus en países latinoamericanos	381
a) Honduras	381
b) Ecuador	381
c) México	381
d) Cuba	381
e) Perú	382
f) Chile	382
4. Antecedentes en la Argentina	382
5. Diferentes categorías de habeas corpus	384
6. El habeas corpus "esclarecedor" aún durante la vigencia del estado de sitio	384
7. Desaparición forzada de personas: protección otorgada	385
8. Habeas corpus colectivo	387
9. A modo de conclusión	389

CAPITULO III.1

LOS RECURSOS EXTRAORDINARIO Y ORDINARIO
ANTE LA CORTE SUPREMA

1. Introducción	391
2. Función del recurso extraordinario	392
3. Requisitos del recurso extraordinario	392

	Pág.
4. Requisitos del control	393
5. Comparación con el sistema federal de EE.UU.	394
a) Proyectos de la Convención Constituyente de Filadelfia	394
b) Competencia federal y estadual	394
b.1) Aplicación de normas federales y estaduais	394
b.2) Conflicto entre distintas jurisdicciones y distintas leyes estaduais	395
b.3) Plena fe de las decisiones de los Estados	395
c) Comparación entre el control de constitucionalidad y el <i>common law</i>	395
6. Requisitos formales y efectos	396
a) Forma, plazo y trámite	396
b) Llamamientos de autos	397
c) <i>Certiorari</i>	397
d) Memorial	397
e) Efectos	398
7. Recurso ordinario	398
a) Requisitos	398
b) Forma y plazo	398
c) Llamamientos de autos	399
d) Posturas de la CSJN sobre admisión y rechazo del recurso ordinario	399
d.1) Circunstancias en que proceden	399
d.2) Circunstancias en que no proceden	399
8. Recurso de queja	400
9. Requisitos formales de la Acordada 4/07	400
10. Audiencia pública	401
11. Conclusión	401

CAPITULO III.2

COMPETENCIA ORIGINARIA Y EXCLUSIVA DE LA CSJN

1. Introducción	403
2. Casos en que procede la competencia originaria y exclusiva	405
a) Los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros	405
b) Cuando alguna provincia fuese parte	405
3. Criterios no uniformes. Empréstitos provinciales en la competencia originaria y exclusiva	406

	Pág.
4. Prórroga de competencia en la competencia originaria y exclusiva	407
5. Requisitos de admisión de la competencia originaria y exclusiva	408
6. Casos en que no procede	408
7. Relación con la Ciudad de Buenos Aires	409
8. Derechos ambientales	409
9. La Corte como tribunal constitucional	410
10. A modo de conclusión	410

CAPITULO IV.1

ACCIÓN DE AMPARO CLÁSICO O INDIVIDUAL

1. Introducción	411
2. Génesis del amparo	412
3. El derecho público provincial y la acción de amparo	413
a) Santa Fe	413
b) Entre Ríos	413
c) Santiago del Estero	413
d) Mendoza	413
e) Chaco	414
f) Provincia de Buenos Aires	414
g) Ciudad de Buenos Aires	414
4. Regulación nacional. Etapas	415
a) Etapa pretoriana (1957-1958 hasta 1966)	415
b) Etapa del amparo reglamentado legislativamente (1966 hasta 1994)	415
c) Etapa del amparo constitucionalizado	417
5. Derechos tutelados en el amparo clásico o individual	418
6. Tipos o clases de amparo	419
a) Amparo Impositivo, Ley 11.683 (t. o. 1978, Ley 21.858)	419
b) Amparo por mora de la Administración – Régimen Nacional de Procedimientos Administrativos Ley 19.549	420
c) Amparo electoral – Código Electoral Nacional, Ley 19.945	420
d) Amparo Sindical – Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales de Trabajadores	421
e) Amparo Aduanero – Código Aduanero Ley 22.415	421
f) Amparo por mora previsional. Ley 24.655	422
g) Amparo ambiental	422
h) Amparo interamericano	422
7. Fundamentos del amparo	422

	Pág.
8. Operatividad del amparo	423
9. El tema de la legitimación activa	424
10. Requisitos de admisibilidad	425
a) Conducta lesiva actual o inminente	425
b) Evidencia de la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta	426
c) Subsidiaridad del amparo	427
11. El amparo como un procedimiento interdictal	427
12. Los actos demandados fuera de plazo	428
a) Distintas posturas	429
a.1) Posición a favor del plazo de caducidad	429
a.2) Posición contraria	430
b) Nuestra posición	432
13. El amparo contra actos del Poder Judicial	432
a) Soluciones en el Derecho Comparado	433
b) Regulación en las provincias	434
c) Doctrina	434
c.1) Tesis negativa	434
c.2) Tesis positiva	435
c.3) Nuestra posición	436
d) Posturas adoptadas por los distintos proyectos de reglamentación del amparo	436
e) Análisis de jurisprudencia	437
e.1) "Federación Judicial Argentina, Asociación Judicial de la Provincia de Jujuy y otros", expte. 36.632, del 02/03/1993..	437
e.2) "Soler, Leopoldo s/ acción de amparo", CFed. Mendoza, sala A, expte. 90485, del 21/2/1992	439
e.3) "Miró Héctor D. s/ acción de amparo", expte. 43.912, 4/8/1959	441
e.4) "Ibarra, Absalón s/ recurso de amparo"	442
14. A modo de conclusión	445

CAPITULO IV.2

EL AMPARO COLECTIVO

1. Introducción	449
2. Antecedentes del amparo colectivo	451
a) Constitución de 1853-60	451
b) Jurisprudencia nacional	452
c) Incorporación constitucional	452
3. Derecho a un ambiente sano apto para el desarrollo humano	453

	Pág.
4. Legitimación o sujeto activo	454
a) El afectado	454
b) El Defensor del Pueblo	456
c) Asociaciones registradas	456
5. Efecto "erga omnes" de sus sentencias	457
6. La creación de un verdadero amparo ambiental	459
7. Consideraciones finales	460

CAPITULO V

LOS PROCESOS COLECTIVOS PARA IBEROAMÉRICA

1. Introducción	463
2. Caracterización jurídica o encuadre jurídico general	464
3. Contexto procesal	464
4. Acción colectiva	465
5. Amparo colectivo	465
6. Derechos de incidencia colectiva general. Supuestos contemplados	465
7. Recaudos de admisibilidad subjetiva para la demanda colectiva ..	466
8. Recaudos de admisibilidad objetiva	467
9. Trámite	467
10. Un planteo innovador: relación jurídica continua vs. efectos de la cosa juzgada	468
11. Especialización y rol del juez	469
12. Conclusión	470

CAPITULO VI

CONCEPTOS ANTIGUOS Y MUNDOS NUEVOS
EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL

1. Introducción	471
2. Globalización y puntos de encuentros del Derecho Constitucional Comparado	472
3. Cláusulas pétreas	474
4. El derecho, la economía y los derechos sociales	474
5. Los derechos de las minorías y pueblos indígenas	475
6. Federalismo. ¿Derecho constitucional subnacional o de la descentralización?	476
7. Puntos de encuentros y reflexiones finales	477

ANEXO DE JURISPRUDENCIA

	Pág.
1. Marbury c. Madison	481
2. Siri, Angel S.	488
3. Samuel Kot S.R.L.	490
4. Mill de Pereyra	496
5. Banco Comercial de Finanzas	501
6. Arancibia Clavel	504
7. Simón, Julio	513
8. Verbitsky, Horacio	529
9. Galli, Hugo	557
10. Bustos, Alberto	571
11. Sánchez, María del Carmen	610
12. Mendoza, Beatriz S.	623
13. Massa, Juan Agustín	635
BIBLIOGRAFÍA	643

PARTE PRIMERA

TEORÍA CONSTITUCIONAL

Todos los derechos reservados

CAPITULO I.1

INTRODUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL

SUMARIO: 1. Introducción. — 2. Situaciones previas al constitucionalismo: Los primeros ordenamientos normativos de la Argentina. — 3. Derecho Constitucional: origen y desarrollo.

1. INTRODUCCIÓN

En una sociedad los individuos para desarrollar mejor sus relaciones entre sí y para buscar en forma mancomunada un fin determinado, buscan una tercera persona que ordene la misma en el logro de dichos objetivos. En una tribu se elige un cacique, en una aldea un jefe, en el sistema feudalista al señor feudal, en una monarquía a un rey, en un estado o nación, más contemporáneamente, a una forma de gobierno por medio de la cual se fijen las bases para ese logro y ello se hace a través de un cuerpo orgánico y sistemático de normas.

En la Argentina ello tardó algo más de cuarenta años, durante los cuales hubo derramamiento de mucha sangre y muertes entre nuestros conciudadanos. Recién la organización se logra con la creación de una carta magna en el año 1853, cuyo art. 1º dispone que la Nación Argentina adopta (no elige o decide) para su gobierno la forma representativa, republicana y federal.

Cuando ya se decide por una forma de gobierno y de Estado, también se crea una nueva relación jurídica entre los representantes del Estado y los ciudadanos. Ambos con reglas y potestades diferentes, el gobierno busca por medio de su obrar el bien común y el bienestar general, y los gobernados que sean respetados sus derechos y garantías.

Históricamente, existieron dos modelos diferentes en que el Estado se daba a sí mismo una Constitución o estaba sometida a ella:

1) En algunos países, la Constitución emana directamente del pueblo soberano en el orden interno, pues es éste, a través de una Convención Cons-

tituyente especialmente convocada al efecto, quien decide sobre su creación y modificación (1).

En esta hipótesis el Estado organizado en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial (llamados "poderes constituidos") no tiene facultades para modificar ni alterar la Constitución: él está siempre sometido a lo que la Constitución determine, por voluntad del pueblo soberano directamente expresada en la Convención Constituyente.

La Convención Constituyente no es un órgano del Estado, sino que representa directamente al pueblo, por ello cabe afirmar en este caso que la Constitución es impuesta por el pueblo al Estado (2).

Como dicen los constitucionalistas alemanes (3) no ha de ser que el Estado tenga una Constitución sino que "esté" en una Constitución: que sea la Constitución la que la contenga a él.

La aspiración de lograr la prevalencia del derecho por sobre el Estado, ha sido la finalidad perseguida por Occidente desde las postrimerías del Siglo XVIII (4), que eclosiona con la construcción germana del "Estado de Derecho" (Von Mohl, 1832).

Este es, en sentido jurídico formal, uno de los principales elementos que tipifican al Estado de Derecho clásico: el sometimiento de toda la organización estatal a un régimen jurídico preestablecido, es decir, con reglas fijadas de antemano. Este era nuestro sistema constitucional antes de la reforma de 1994 (5). Es decir, su objetivo principal es limitar el accionar de los gobernantes, colocando el imperio de la ley por sobre todo poder políticamente establecido. Este sistema es el utilizado en toda Constitución Republicana, en la que se echan los cimientos para la organización del derecho público.

El ilustre publicista Juan Bautista Alberdi decía que la Constitución se supone hecha por el pueblo y emana del pueblo soberano, no para refrenarse a sí mismo, ni para poner límite a su propio poder soberano, sino para refrenar y limitar a sus delegatarios, que son los tres poderes que integran el gobierno nacional (6).

2) En otros sistemas, en cambio, la Constitución no proviene directamente del pueblo, excluyendo la intervención de los órganos estatales normales,

(1) GORDILLO, AGUSTÍN, *Tratado de Derecho Administrativo*, Buenos Aires, t. 1, p. III.20.

(2) Idem, p. III.21.

(3) MAUNZ, THEODOR, *Deutsches Staatsrecht*, 9ª edición, Munich y Berlín, 1959, p. 37.

(4) SABSAY, DANIEL y ONAINDIA, JOSÉ MIGUEL, *La Constitución de los Argentinos*, Errepar, 4ª edición, 1997.

(5) Se recuerda que *soberanía* no es una palabra más sino la más importante del Derecho Constitucional, ya que, el que ostenta la soberanía tiene un poder ilimitado, no sujeto a norma imperativa alguna. Entonces resulta indispensable que solo la ostente el pueblo y no la organización estatal.

(6) ALBERDI, JUAN BAUTISTA, *Escritos póstumos*, Buenos Aires, 1899, t. X, p. 125.

sino que por el contrario emana indirectamente del Estado, a través de sus órganos regulares —en este caso el Poder Legislativo— que es quien crea y reforma la Constitución. De ese modo, el poder soberano del pueblo no es ejercido por éste, sino que es ejercido directamente por el propio Estado.

El Estado no nace de una Constitución, sino que la Constitución nace del Estado, con el contenido y alcances que éste decida: no es el Estado el que está contenido dentro de la Constitución, sino la Constitución la que está contenida dentro del Estado. Este sistema es típico en constituciones monárquicas, estableciendo un pacto jurado entre el rey y el pueblo, que establece los principios básicos de la legislación y del gobierno dentro de un país.

3) En la actualidad, estos dos sistemas se han debilitado, por el avance cada vez más importante de un orden jurídico supranacional, que también impone limitaciones al Estado dentro de la comunidad Internacional, frente a los demás países y con relación a los derechos humanos de sus propios habitantes.

En nuestro país el art. 75 inc. 24 de la CN establece la facultad del Congreso de aprobar tratados internacionales con transferencia de jurisdicción a organismos supranacionales, sin la obligación normal de someterlo a consulta popular, ni hay tampoco derecho de iniciativa popular, aunque no se excluye la consulta popular del art. 40 al respecto.

2. SITUACIONES PREVIAS AL CONSTITUCIONALISMO

Los primeros ordenamientos normativos de la Argentina:

En ocasión de uno de los tantos conflictos con Portugal, suscitado en 1776, el rey Carlos III decidió la creación del Virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires (7).

Las tres medidas político-administrativas (8) impuestas por la Corona española en nuestro territorio que inauguran nuestro "primer derecho propio" por ser específicos destinatarios de aquél, fueron: 1) La creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, 2) La sanción del Reglamento y Aranceles Reales para el comercio libre de España e Indias en 1778 y, 3) la implantación de la Real Ordenanza de Intendentes o sistema intendencial en 1782.

Luego de la Revolución de Mayo, los pueblos del interior fueron adhiriendo a su causa con la esperanza de concretar un gobierno que respetara las necesidades de sus localismos (9). Pero tuvieron que esperar hasta el año 1820 para que a través de la Batalla de Cepeda le fueran reconocidas las autonomías estatales.

(7) ZUCCHERINO, RICARDO M., *Tratado de derecho federal, estadual y municipal*, Buenos Aires, 1992.

(8) DROMI, ROBERTO, *Derecho Administrativo*, 5ª ed., Buenos Aires, 1996.

(9) ZUCCHERINO, RICARDO M., *Ley orgánica de las municipalidades*, Buenos Aires, 1998.

3. DERECHO CONSTITUCIONAL: ORIGEN Y DESARROLLO

El derecho constitucional es la rama del derecho público que tiene por objeto estudiar las normas que se refieren a la estructura del Estado, a la organización y competencia de los poderes del gobierno y a los derechos, garantías y obligaciones individuales y colectivos, así como las instituciones que los garantizan, como también la jurisprudencia, doctrina, práctica, usos y costumbres nacionales (10).

Duverger sostiene que poco a poco el derecho constitucional se va disminuyendo para transformarse en un derecho de las instituciones y de los regímenes políticos.

El derecho constitucional nace a fines del siglo XVIII al sancionarse la constitución federal de los EE.UU. de Filadelfia de 1787 y la primera carta orgánica francesa de 1791. Después siguieron muchas otras, como la de Suecia de 1809, la de Noruega de 1814, la de Bélgica en 1831, la de Suiza de 1848 y la de Dinamarca de 1849.

Cronológicamente, la primera cátedra de derecho constitucional fue creada en la Universidad de Oxford e inaugurada el 25 de octubre de 1758, siendo su primer profesor William Blackstone. En Inglaterra y en EE.UU. la expresión *constitutional law*, es la empleada para denominar a la materia, pero también se emplea la expresión *Government and administration* que tiene un sentido más práctico (11).

En Francia recibió su estructura definitiva en 1819, con el nombre de derecho público.

La primera cátedra de derecho público de nuestro país fue la establecida en la Universidad de Córdoba el 19 de febrero de 1834 y la primera obra de texto argentino puede considerarse el Dogma Socialista de Esteban de Echeverría. Luego vinieron las importantes obras de Juan Bautista Alberdi y Sarmiento (éste realizó la primera obra sobre la materia denominada: "Lecciones de derecho constitucional", año 1859).

Sarmiento fue profesor titular en el año 1855 cuando la materia se denominaba: "Derecho constitucional y administrativo".

En la actualidad tan solo la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires tiene 8 profesores titulares (6 titulares, 1 asociado y 1 adjunto a cargo de Cátedra), 50 profesores adjuntos regulares —aproximadamente—, un número muy significativo de Jefes de Trabajos Prácticos, y más de un centenar de Auxiliares.

Por la importancia que reviste la materia en un estado de derecho constitucional en la carrera de abogacía es considerada como la base conceptual y jurídica de todo profesor, de todo abogado y de todo estudiante de derecho.

(10) PEREIRA PINTO, *Manual de Derecho Constitucional*, vol. I, Buenos Aires, 1978.

(11) Idem.

CAPITULO I.2

OBJETO, FUENTES Y MÉTODO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL. RELACIÓN CON OTRAS DISCIPLINAS

SUMARIO: 1. Introito. — 2. Perfiles del objeto del derecho constitucional. — 3. El sistema de fuentes del derecho constitucional. 3.1. Las fuentes. Clasificación. 3.2. La Constitución, los tratados constitucionales y las leyes constitucionales. 3.3. El derecho judicial o jurisprudencia de los tribunales. 3.4. La costumbre constitucional. — 4. Concepto de Constitución. — 5. Clasificación de constituciones. — 6. Tipos de constituciones. — 7. Clasificación de las normas constitucionales. — 8. Metodología del derecho constitucional. 8.1. El método. 8.2. Técnica. 8.3. Enfoques. — 9. Relaciones con otras disciplinas. 9.1. Con la ciencia política. 9.2. Con otras ciencias de la conducta (sociología, psicología social, antropología). 9.3. Con la economía. 9.4. Con la historia.

1. INTROITO

Detectamos una realidad política primaria, que es el *estado*. La ciencia política ha brindado diferentes conceptos clave de lo que entiende por *estado*. Una de las definiciones más comprensivas sugiere que el estado es una comunidad jurídico-política organizada (1), que abarca varios elementos constitutivos (territorio, población, poder y/o gobierno, soberanía, derecho, sistema económico, valores); empero, las más restrictivas lo identifican con el fenómeno del *poder*, es decir, *con tan solo uno de sus elementos integrantes (aunque tal vez el más importante) (2)*.

Como sea, la noción de "estado" involucra la idea de organización, de estructura o de ordenamiento de la relación política de mando y obediencia.

(1) BIDART CAMPOS, GERMÁN J., *Lecciones Elementales de Política*, Lima, 2002, p. 9.

(2) Hay autores que se empeñan en colocar el centro de atención en el fenómeno del poder. Así, se ha dicho que "la definición del Estado como poder es la que determina el contenido y la estructura del Derecho Constitucional, que no consiste sino en la exposición de cómo avanza el Estado en su proceso de su juridificación. Pues el Derecho Constitucional no es más que el estudio del proceso a través del cual el Estado se somete al Derecho; es decir, el estudio del proceso a través del cual el Estado se convierte en Estado de Derecho". V. PÉREZ ROYO, JAVIER, *Curso de Derecho Constitucional*, Madrid y Barcelona, 2005, p. 69.

El estado se revela así como un dato político primigenio, pero también como fenómeno jurídico. Esa organización que conlleva el estado se reviste y se barniza de *juridicidad*; es simultáneamente, política y jurídica a la vez. Con habitual claridad, lo explica Germán Bidart Campos: "Cuando nos referimos a la organización política de la convivencia, la misma voz 'organización' involucra las de ordenación y la de orden. El orden *social* es, a la vez y necesariamente, un orden *político*, un orden vinculante de la convivencia, y un orden *jurídico*, porque el orden social no puede existir ni perdurar sin la organización política y jurídica que erige una jefatura montada sobre la dualidad de gobernantes y de gobernados" (3).

Dentro de las sectorizaciones que reconoce el ordenamiento jurídico, hay una rama que se ocupa de la instalación o inserción de la persona humana en el estado, la distribución de las magistraturas dentro del gobierno, la masa de competencias de cada órgano, etc. Es decir, se ocupa de relaciones verticales y horizontales que se anudan dentro del estado (4). Y esa área del derecho es, ni más ni menos, que el *derecho constitucional*.

Lo dicho hasta aquí sirve para sostener que el derecho constitucional proporciona *el necesario encuadre jurídico al fenómeno político* (5).

De ese modo, los procesos políticos no marchan a la deriva, sin rumbo fijo. Por el contrario, *hallan su canalización y cauce a través del derecho constitucional*. La dinámica política encuentra su cauce en las vertientes constitucionales.

2. PERFILES DEL OBJETO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL

Podría aseverarse, como hace un sector de la doctrina (6), que el objeto de la ciencia del derecho constitucional es el estudio de las *instituciones políticas*.

(3) BIDART CAMPOS, GERMÁN J., *El régimen político. De la 'politeia' a la 'res publica'*, Buenos Aires, 1979, p. 52.

(4) Se ha señalado que "en términos clásicos, la Constitución cumple tres funciones principales. Primero, organiza y distribuye los poderes entre los diferentes poderes de gobierno en una sociedad determinada. Podríamos llamar a éstas las previsiones horizontales. En segundo lugar, prevé la protección de ciertos principios y derechos individuales que, por la misma razón de derivar de la constitución, son llamados 'fundamentales'. A estas las llamaríamos las previsiones verticales. La tercer función es la de proveer garantías para asegurar que los cuerpos gubernativos, en ejercicio de los poderes conferidos bajo las previsiones horizontales, no infrinjan los derechos concedidos a los individuos bajo las previsiones verticales". V. VESTERDORF, BO, *A Constitutional Court for the European Union?*, en "International Journal of Constitutional Law", vol. 4, núm. 4, New York, octubre de 2006, p. 608.

(5) Acertadamente, Pérez Royo afirma que el Derecho Constitucional "es un Derecho de mínimos, o si se prefiere, un Derecho de límites". V. PÉREZ ROYO, JAVIER, op. cit., p. 59.

(6) Así, p. ej., LINARES QUINTANA, SEGUNDO V., *Derecho constitucional e instituciones políticas*, Buenos Aires, 1976, tomo I, ps. 213 y 233, entre muchas otras.

Así, muchas obras de la asignatura —sobre todo las originadas en Francia— comenzaron a adicionar al tradicional nombre del derecho constitucional, el aditamento de las *instituciones políticas* (7).

Dentro de este marco de análisis, una diferenciación que conviene tener presente es aquella que distingue entre *estructura constitucional* y *proceso constitucional*.

El primer concepto está dado por el entramado normativo-institucional en sí mismo. La presidencia, el gabinete, el congreso, la corte suprema, el consejo de la magistratura, el ministerio público, la defensoría del pueblo, son todas *estructuras* constitucionales argentinas. También lo son las universidades nacionales y las provincias, dotadas de *autonomía*.

A la inversa, el *proceso* constitucional se conecta estrechamente con la dinámica del poder político. Las transiciones, la democratización, la participación, la comunicación, el liderazgo, la obediencia, son todos fenómenos que pertenecen a este grupo.

También dentro del derecho constitucional se ha propiciado establecer una porción dedicada a la parte dogmática de la constitución —Bidart Campos habla de un "*derecho constitucional de la libertad*" (8)—, mientras que otra gran área se ocupe de la parte orgánica ("*derecho constitucional del poder*").

En realidad, esta división (9) responde a la sistemática de la mayoría de los textos constitucionales, que exhiben un segmento *dogmático* (comprensivo de un catálogo de los derechos subjetivos) y otro *orgánico* (v.gr., los órganos constituidos: el legislativo, el ejecutivo y el judicial). Ya el mundialmente famoso artículo 16 de la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano lo anticipaba con claridad: "*Toda sociedad en la que no estén declarados los derechos ni se dividan los poderes, carece de constitución*" (10).

3. EL SISTEMA DE FUENTES DEL DERECHO CONSTITUCIONAL

a) Las fuentes. Clasificación

Las fuentes del derecho constitucional son las formas o modos de manifestación de las normas jurídico-constitucionales, y comprende —según

(7) La bibliografía de esta tendencia es realmente muy copiosa. Valen algunos ejemplos: DUVERGER, MAURICE, *Instituciones políticas y derecho constitucional*, Barcelona, 1970; HAURIOU, ANDRÉ, *Derecho constitucional e instituciones políticas*, Barcelona, 1971; BURDEAU, GEORGES, *Derecho constitucional e instituciones políticas*, Madrid, 1981; JEANNEAU, BENOIT, *Droit constitutionnel et institutions politiques*, Paris, 1991; en la obra de PARINI, PHILIPPE, *Les institutions politiques*, Paris, 1984, vemos que se suprime directamente en el título la locución "derecho constitucional".

(8) BIDART CAMPOS, GERMÁN J., *Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino*, Buenos Aires, 2000, tomo I-A, p. 291.

(9) Que no debe implicar inconexión o divorcio, como se observa con el art. 75 inc. 22 C.N.

(10) Para un estudio de este enunciado, véase TROPER, MICHEL, *L'interprétation de la déclaration des droits. L'exemple de l'article 16*, en "Droits" (Revue française de théorie juridique) núm. 8, Paris, 1988, p. 111 y sigtes.

17

Badeni (11)— tanto los procedimientos de manifestación (*fuentes formales*) como los factores que determinan su contenido (*fuentes materiales*). Ambas, a su vez, se subdividen en directas o inmediatas (Constitución, leyes constitucionales y costumbre) e indirectas o mediatas (jurisprudencia, doctrina, derecho comparado) (12).

b) La Constitución, los tratados constitucionales y las leyes constitucionales

Entre las primeras, y en un lugar central, hallamos a la propia constitución formal o documental. Obviamente, la primera fuente a la que acudirá el intérprete será a la *letra* y al *espíritu* del texto constitucional. Empero, ello de ninguna manera puede significar que todo el derecho constitucional se encuentre reducido al código fundamental (13).

Una de las aperturas más significativas que registra el derecho constitucional de fines del s. XX y comienzos del s. XXI es la *creciente aceptación de las fuentes oriundas del derecho internacional público*. En las últimas décadas, se ha verificado una creciente constitucionalización del derecho internacional (14), consistente en dotar a los tratados internacionales —sobre todo, a aquellos que regulan aspectos concernientes a los derechos humanos o al derecho comunitario y de la integración— de una especial jerarquía y relevancia dentro de la pirámide del orden normativo (15).

Las llamadas *leyes constitucionales* revisten un doble perfil. Desde una angulatura estrictamente formal, no se diferencian de la legislación ordinaria, o sea, han sido sancionadas por el Congreso y promulgadas por el ejecutivo con arreglo a los procedimientos pautados constitucionalmente. Empero, son *materalmente constitucionales* ya que los temas que regulan complementan al texto fundamental. Las leyes de amparo, hábeas corpus, hábeas data, acefalía, ministerios, de consulta popular, del consejo de la magistratura, del ministerio público, el código electoral nacional, etc., revisten esta calidad, que en Argentina son —por cierto— una creación doctrinaria.

(11) BADENI, GREGORIO, *Derecho constitucional (Libertades y garantías)*, Buenos Aires, 1993, p. 49; ídem, *Tratado de Derecho Constitucional*, Buenos Aires, 2005, tomo I, p. 10. Sobre esta problemática, ver CARNOTA, WALTER F., *Curso de Derecho Constitucional*, Buenos Aires, 2001, ps. 2 y sigtes.

(12) A los fines estrictamente pedagógicos, hemos simplificado la temática de las fuentes del derecho, que cada vez más hunde sus raíces en la teoría constitucional. Conf. ALVAREZ CONDE, ENRIQUE, *Curso de Derecho Constitucional*, vol. I, Madrid, 1992, ps. 131/ 132. Prueba de esta complejidad es que hay doctrina, p.ej., que distingue a las fuentes escritas (Constitución y leyes), no escritas (costumbre y principios generales del derecho) e indirectas (tratados internacionales y jurisprudencia). V. MERINO MERCHÁN, JOSÉ FERNANDO; PÉREZ-UGENA COROMINA, MARÍA y PÉREZ SANTOS, JOSÉ M., *Lecciones de derecho constitucional*, Madrid, 1997, ps. 122/123.

(13) Lo cual representaría una postura exageradamente positivista desde lo normológico.

(14) CARNOTA, WALTER F., *Constitución de la Nación Argentina, Comentario General*, Buenos Aires, 1995, p. 49.

(15) Las distintas soluciones pueden verse en BIDART CAMPOS, GERMÁN J., y CARNOTA, WALTER F., *Derecho Constitucional Comparado*, Buenos Aires, 1998, tomo I, ps. 107 y sigtes.

c) El derecho judicial o jurisprudencia de los tribunales

Otra fuente constitucional de suma relevancia, pero de naturaleza indirecta, es el *derecho judicial*. Los jueces no se limitan a ser "meros aplicadores de la norma legal" (los magistrados "boca de la ley" de los que hablaba Montesquieu), sino que al interpretar las reglas generales y abstractas introducen pautas y criterios de valoración que es menester computar. Por lo demás, el derecho constitucional registra célebres "creaciones judiciales", como ser —entre nosotros— el control de constitucionalidad (al igual que en los Estados Unidos), las cuestiones políticas no judiciales, la acción de amparo, la noción constitucional lata de "propiedad privada" y la doctrina de arbitrariedad de sentencias para la procedencia del recurso extraordinario federal, por citar tan sólo algunos ejemplos.

La jurisprudencia es esencialmente dinámica, y permite en muchas ocasiones la adaptación de textos más antiguos a la realidad actual. Sobre todo en derecho constitucional, interesará el aporte de la jurisprudencia de los altos tribunales, sean éstos cortes supremas, cortes constitucionales (en los sistemas de control concentrado de constitucionalidad) o tribunales internacionales de derechos humanos o de la integración.

Bien se ha dicho que: "La complejidad de la vida y las exigencias de una gran comunidad política no permite que la Suprema Corte se dé el lujo de establecer y luego aplicar mecánicamente reglas rígidas. Tampoco el lenguaje amplio existe en cualquier texto constitucional. No existe una interpretación 'literal' del 'debido proceso' ni de la 'protección igualitaria'. Esas palabras expresan valores en forma de principios. Son un mandato para que la Corte adapte esos valores a las condiciones cambiantes de la vida nacional, para encontrar el medio de su expresión que sustente su base y el sentido de la comunidad de tener una identidad moral coherente, al tiempo que respete las necesidades prácticas de la misma comunidad en un mundo complejo" (16).

d) La costumbre constitucional

También el *derecho consuetudinario* es una fuente del derecho constitucional (directa y no escrita). La costumbre, para originar derecho, requiere de dos elementos: uno de índole objetivo (la repetición de actos concordantes en el tiempo), y uno subjetivo (la convicción de la obligatoriedad jurídica de esas conductas).

Muchas cuestiones, tanto en el derecho constitucional argentino como en el comparado, son gobernadas por el derecho consuetudinario. Gran parte del proceso de revisión constitucional argentino descansa sobre prácticas consuetudinarias, dado que el art. 30 C.N. suministra tan sólo pautas mínimas. Una vasta porción de la constitución dispersa británica tiene su génesis

(16) FARER, TOM, *Las obligaciones de la Corte constitucional en un estado democrático*, en AA.VV., "Seminario sobre jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", Buenos Aires, 1999, p. 49.

en la costumbre, como también la tiene el crecimiento de atribuciones de la presidencia en los Estados Unidos.

No todos los autores son contestes en aceptar a la costumbre como fuente constitucional. En sintonía crítica, se ha argumentado que "desde una perspectiva de legitimidad política, resulta difícilmente admisible que puedan crearse normas fundamentales que no provengan de la voluntad de la comunidad, sino de la práctica de algunos órganos o poderes públicos. La creación de normas constitucionales por vía consuetudinaria supondría, de hecho, dejar en manos de unos pocos individuos la elaboración de normas fundamentales para la organización de la comunidad. Ello resulta especialmente inadmisibles en el caso de la costumbre *contra constitutionem*, en que la voluntad del constituyente (de la comunidad política) se vería anulada por la conducta repetida de unos pocos individuos" (17).

Claro está que hay fuentes materiales que revisten una importancia aún inferior, al menos en cuanto a la fuerza vinculante de sus opiniones. La doctrina de los autores orienta a los constituyentes (recordemos a Alberdi), a los legisladores y a los jueces. Pero ello dependerá en gran medida de la solidez de las posiciones sustentadas, de la consistencia en el razonamiento empleado o de la cantidad de veces a que se acude a su autoridad (p.ej. los autores norteamericanos para la Corte Suprema Argentina de las primeras décadas de la organización nacional) (18).

El *derecho comparado* también puede ser útil debido a los factores arriba mencionados. La experiencia constitucional extranjera sirve en la medida en que permite plantearse problemas comunes y evaluar cursos alternativos de acción frente a determinadas encrucijadas (19).

4. CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN

Puede decirse sin temor a equivocarnos, como lo han explicado diversos autores y sistematizado Ignacio de Otto, que no hay uno sino dos conceptos centrales de Constitución.

Bajo una primera perspectiva, el concepto de constitución ha sido funcional a una determinada realidad histórica, es decir es producto de un momento dado, que es la época del constitucionalismo. Así, llegamos a un concepto político de Constitución.

Sobre el tema, bien explica este autor que "*la finalidad del movimiento que históricamente se llamó constitucionalismo no era, obviamente, introducir*

en los ordenamientos una norma denominada Constitución, sino asegurar la garantía de la libertad frente al poder público. Que una sociedad tenga Constitución, que un Estado sea constitucional, significa, ante todo, que en él la organización de los poderes responda a un determinado fin, el aseguramiento y garantía de la libertad de los ciudadanos. Luchar por la libertad es, así, luchar por la Constitución, y constitucionalismo y liberalismo aparecen como términos equivalentes, porque en ese significado la palabra Constitución designa algo más que una norma jurídica: la propia organización del Estado que obedece a determinados principios" (20).

Paralelamente, existe el concepto jurídico de Constitución, que evoca la calidad de *norma fundamental de organización del Estado o régimen político* (21). Dentro de esta visión, asume una cualidad esencial su fundamentalidad o supra-legalidad. La Constitución se autoproclama o erige en suprema, y se define como de mayor rango *en relación con la legislación ordinaria*.

5. CLASIFICACIÓN DE CONSTITUCIONES

a) Constitución formal o material

Una distinción básica es aquella que diferencia Constitución material de Constitución formal.

La Constitución formal viene a estar dada por la propia codificación constitucional; en el caso argentino, los 129 artículos de su texto más el art. 14 bis (repárese que los tratados internacionales del art. 75 inc. 22 gozan de "jerarquía constitucional" pero no están dentro del propio articulado de la misma Constitución).

Por el contrario, la Constitución material evoca una noción mucho más abarcadora, que equivale a la Constitución vigente, a la realmente vivida y practicada tanto por los detentadores como por los destinatarios del poder. Algunos autores como Bidart Campos la consideran sinónima con la de régimen político, y los pensadores norteamericanos hablan de una "living constitution" (constitución viviente) como análoga a un organismo de la biología que nace, se desarrolla y fenece.

b) Constitución rígida o flexible

James Bryce (22) introdujo la clasificación de constituciones rígidas como opuestas a constituciones flexibles. Las rígidas son las que requieren para su reforma de un proceso distinto al que se utiliza a la hora de sancionar una ley

(17) LÓPEZ GUERRA, LUIS, *Introducción al Derecho Constitucional*, Valencia, 1994, p. 67.

(18) HUERTAS, MARTA MARÍA MAGDALENA, *El modelo constitucional norteamericano en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (1863-1903)*, Buenos Aires, 2001.

(19) BIDART CAMPOS, GERMAN J., y CARNOTA, WALTER F., *Derecho Constitucional Comparado*, tomo I ya cit., cap. I.

(20) DE OTTO, IGNACIO, *Derecho Constitucional (Sistema de Fuentes)*, Barcelona, 2001, p. 12.

(21) SÁNCHEZ AGESTA, LUIS, *Curso de Derecho Constitucional Comparado*, Madrid, 1980, p. 49.

(22) BRYCE, JAMES, *Flexible and Rigid Constitutions*, en "Studies in History and Jurisprudence", Oxford, vol. I, ps. 124 a 213; ídem, *Constituciones rígidas y flexibles*, Madrid, 1952.

común. P. ej.: los Estados Unidos con el mecanismo de "enmiendas" (art. 5º, Constitución de Filadelfia), o el art. 30 de la Constitución argentina que requiere para la reforma de una Asamblea Constituyente convocada al efecto. Las flexibles son aquellas que no matizan entre la supremacía formal de la Constitución y la ubicación institucional de la ley. Dicho de otra manera, el Parlamento puede iniciar cambios en la Constitución, tal como si modificase una ley ordinaria. P. ej.: la parte "estatutaria" de la Constitución británica (formalmente, no tiene mayor supremacía que la ley común).

c) Constitución originaria o derivada

Otro distingio relevante es aquel que diferencia a las Constituciones originarias de las Constituciones derivadas.

Las primeras son aquéllas que fundan un nuevo régimen político, como sucedió p. ej. con la Constitución norteamericana de 1787. Con anterioridad a su sanción, no se registraban casos de forma de gobierno presidencialista ni de forma de estado federal. Se podría decir que tienen una pretensión de innovación y de originalidad.

La Constitución derivada, en cambio, es la que sustancialmente reitera o repite instituciones plasmadas en textos anteriores. Por ejemplo, la Constitución argentina de 1826 reeditó los planteos unitarios de la Constitución anterior de 1819. La primera, entonces, es "derivada" de la segunda.

d) Constitución monárquica o republicana

También pueden hallarse constituciones monárquicas y constituciones republicanas. Esta división se estructura sobre la base de la respectiva forma de gobierno. Sin embargo, puede resultar equívoca. Tanto Gran Bretaña como Arabia Saudita exhiben constituciones monárquicas, y son bien disímiles entre sí. Del mismo modo, Estados Unidos, Chile e Irán tienen constituciones republicanas, y son más notables las disimilitudes que los parecidos.

e) Constituciones normativas, nominales y semánticas

Loewenstein (23) finalmente nos habla de su célebre criterio ontológico. El mismo compagina la norma con la realidad existencial. En tal sentido, pueden encontrarse constituciones normativas, nominales y semánticas.

- Las primeras mentan un perfecto ajuste entre la norma y la realidad; la Constitución es como "un traje que queda bien".
- Las segundas registran algún desajuste entre ambas variables, fruto de la falta de educación y de una clase media. Es como un traje que resulta grande, y que hay que esperar al crecimiento para que quede justo. Hay muchos ejemplos latinoamericanos en esta categoría.

(23) LOEWENSTEIN, KARL, *Teoría de la Constitución*, Barcelona, 1979, p. 216.

- Finalmente, las constituciones semánticas enmascaran un ejercicio autocrático del poder detrás de una "fachada" democrática. Ejemplos: algunas constituciones africanas, donde el texto constitucional viene a operar como disfraz.

6. TIPOS DE CONSTITUCIONES

Manuel García Pelayo (24) aportó una célebre "tipología" que intenta construir tres modelos distintos de Constitución.

- El tipo *racional-normativo* de Constitución apunta, como su nombre lo indica, a un molde de tipo ideal, que se emparenta con la filosofía de la ilustración del s. XVIII. Concretamente, este tipo constitucional postula que la Constitución es un producto exclusivamente originado en la razón humana, que es todopoderosa y que puede fundar estados de la nada. Ejemplo: las constituciones francesas de fines del s. XVIII, fruto del ideario revolucionario.
- El tipo *histórico-tradicional* de Constitución se basa en la legitimidad histórica. Bucea dentro de los usos y costumbres, que darán el soporte ancestral a la formación (lenta y evolutiva) del Derecho. Piensa que la Constitución es una derivación abonada por el tiempo. Ejemplo: la constitución británica, que amalgama o fusiona elementos medievales, modernos y contemporáneos.
- Por último, el tipo *sociológico* de Constitución apunta al conjunto de factores de poder que registra una sociedad determinada en un momento dado (25). Se identifica con lo que algunos autores llaman "constitución real".

7. CLASIFICACIÓN DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES

Si bien todas las normas constitucionales tienen el mismo valor y efecto (tal como propugna la llamada interpretación armónica, conciliadora o sistemática), ello no impide su clasificación:

1) *Normas operativas y normas programáticas*: Las primeras son directamente auto-aplicativas o auto-ejecutorias, sin que requieran ineludiblemente del despliegue reglamentario del legislador. Ejemplo: los derechos individuales. Por el contrario, las programáticas denotan un proyecto a realizar en el futuro, merced a la intervención del Congreso. Ejemplo: la "participación en las ganancias de las empresas" a las que alude el art. 14 bis, aún no implementado.

(24) GARCÍA PELAYO, MANUEL, *Derecho Constitucional Comparado*, Madrid, 1999, ps. 33 y sigtes.

(25) LASALLE, FERDINAND, *Qué es una Constitución*, Buenos Aires, 1984, p. 70.

2) *Cláusulas pétreas y normas susceptibles de reforma*: Las cláusulas pétreas son aquellas que resultan irreformables, con vocación de "eternidad". En el derecho constitucional argentino, por vía de principio todas las reglas son susceptibles de revisión, a tenor de lo que dispone el art. 30 del plexo de base. La Constitución de Filadelfia, en cambio, declara irreformable a la paridad en la representación senatorial (art. quinto, *in fine*). Parte de la doctrina argentina ha discernido la existencia de "contenidos pétreos" como el federalismo y la forma republicana de gobierno.

3) *Normas permanentes y normas transitorias*: Los ciento treinta artículos de la Constitución (los primeros 129 más el 14 bis) tienen vocación de permanencia, no así las subsiguientes diecisiete "Disposiciones Transitorias".

4) *Normas de organización y normas que reconocen derechos personales*: Responde a la división entre parte orgánica (arts. 44 a 129) y dogmática (arts. 1º a 43) del texto cívico. Las primeras se caracterizan por contener normas básicamente de índole competencial (art. 75; art. 99; etc.).

8. METODOLOGÍA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL (26)

a) El método

Etimológicamente, *método* significa "camino a seguir". Desde el punto de vista científico, el método evoca al recorrido intelectual que emprende todo investigador. Facilita decisivamente la reconstrucción de sus pasos y es índice cierto de que el conocimiento científico es un saber *ordenado y pautado*.

Pese a discusiones epistemológicas, puede afirmarse que existen dos grandes métodos: el *deductivo*, y el *inductivo*.

- Como se sabe, el primero —usado fundamentalmente por las ciencias denominadas formales, como la matemática y la lógica— se caracteriza por partir de premisas generales, para arribar a conclusiones particulares. El ejemplo clásico de método deductivo lo configura la estructura lógica del *silogismo*.

Si aplicamos estas nociones al campo del derecho constitucional, advertiremos que las sentencias de los tribunales (la fuente del derecho judicial, que ya hemos visto) por lo general exhiben un diseño similar al silogismo. Ejemplos: 1) El art. 99 inc. 3 C.N. prohíbe al presidente el dictado de decretos de *necesidad y urgencia* en materia *tributaria* (premisa mayor); 2) El P.E. ha dictado el decreto *x* de necesidad y urgencia creando impuestos (premisa menor); 3) El decreto *x* es inconstitucional (conclusión).

- A la inversa, el otro gran método es el *inductivo*. Propio de las llamadas ciencias fácticas—como la biología o la medicina—, el inductivis-

mo metodológico toma como punto de arranque al *dato individual y concreto*, para luego estar en condiciones de proyectar una conclusión más general.

Nuevamente, el derecho judicial puede proporcionarnos un ejemplo para el derecho constitucional. Si el tribunal A declara la inconstitucionalidad de la ley que consagra la indisolubilidad del vínculo matrimonial, el tribunal B hace lo propio, el C también, y así sucesivamente, es *dable concluir* (27) que existe una regla de derecho judicial proclive a admitir tales planteos (28).

¿Cuál es la *mejor* metodología para emplear en el terreno del derecho constitucional? La respuesta no es unívoca. Como analizáramos, el derecho constitucional puede utilizar *indistintamente* el método deductivo, o el inductivo, o incluso a uno que combine a ambos (en cuyo caso lo denominamos *método complejo*). La elección del método dependerá del investigador y del objeto a estudiar.

Así, hay tópicos dentro del derecho constitucional, como p. ej. los propios de la teoría constitucional, que se compadecen más con un tratamiento metodológico deductivo que con uno inductivo. Por el contrario, cuestiones atinentes a la dinámica constitucional, como ser el impacto o incidencia de los partidos políticos y factores de presión sobre los detentadores formales del poder, por lo general son encarados por vía inductiva. El indudable sustrato fáctico de tales fenómenos los torna especialmente aptos para la inducción.

b) Técnica

Más próximas o cercanas al objeto de investigación que los métodos, nos encontramos con las *técnicas*.

De hecho, el método se descompone en una serie de opciones o alternativas, que son las técnicas. Conforman mecanismos de recolección de información ("data gathering"), elementos que posteriormente serán procesados por el método.

b.1) Técnicas cuantitativas y cualitativas

Una primera clasificación sugiere que deben discriminarse las *técnicas cuantitativas* de las *técnicas cualitativas*.

(27) Guibourg, Ghigliani y Guarinoni destacan el carácter de meras "probabilidades" que establece el método inductivo, que pueden aparecer refutadas por la irrupción de un nuevo dato. Ver GUIBOURG, RICARDO A.; GHIGLIANI, ALEJANDRO M., y GUARINONI, RICARDO V., *Introducción al conocimiento científico*, Buenos Aires, 1991, p. 167.

(28) Ello es lo que aconteció con la posición asumida por la Corte Suprema argentina cuando en autos "Sejean c. Zaks de Sejean" (sentencia del 27 de noviembre de 1986), Fallos: 308:2268, declaró por mayoría la inconstitucionalidad de la indisolubilidad del vínculo matrimonial, precipitando la ley de divorcio vincular.

- Las primeras tienen que ver, como su nombre insinúa, con el uso de modelos matemáticos o numéricos.

De menor atinencia en el derecho constitucional, irrumpieron en la ciencia política norteamericana a partir de la década de 1960.

El uso de estadísticas, encuestas de opinión, gráficos y cuadros comparativos se convirtió en prevalente, suscitando reparos aún para aquellos que propiciaban una integración entre la ciencia política y el derecho constitucional (29).

- Inversamente, las técnicas por excelencia en el ámbito del derecho constitucional son las de índole *cualitativa*. A diferencia de las anteriores, las segundas se orientan directamente hacia el *contenido* de los datos, y no hacia su capacidad de medición y de cuantificación.

El análisis de textos documentales, p.ej., es una herramienta muy útil para los constitucionalistas. Al indagar acerca de una constitución, v.gr. la argentina de 1853-1994, interesará destacar las influencias doctrinarias, las filiaciones filosófico-políticas, los modelos seguidos, sin perjuicio de adentrarse en su sistemática y hasta en su estilo, tanto del instrumento originario, como de sus reformas (30).

b.2) Técnicas de elaboración y de interpretación

Otra clasificación separa las *técnicas de elaboración* de las de *interpretación*.

- Las primeras tienen que ver con el proceso previo al establecimiento de una constitución, y deben ser tenidas muy en cuenta por sus redactores. Hay, por ejemplo, técnicas constitucionales de elaboración que postulan la concisión y la brevedad por encima del excesivo declaracionismo, la claridad por sobre el barroquismo, y la precisión lexical contra las normas de textura muy abierta. Estas enseñanzas no siempre han sido acatadas (31).
- Por otro lado, hallamos las famosas *técnicas de interpretación*, que aluden a las estrategias que el intérprete despliega para determinar el sentido y el significado de una norma constitucional (ver *infra*).

(29) Tal como lo postulaba SEGUNDO V. LINARES QUINTANA en *Derecho constitucional e instituciones políticas*, ob. y t. cit., p. 137.

(30) En tal sentido, la técnica constitucional desplegada al elaborar la revisión constitucional de 1994 no fue, precisamente, un dechado de virtudes, lo que llevó a Germán Bidart Campos a escribir un provocativo artículo periodístico —coetáneo a la sanción de la reforma— que llevaba por título "Ni mamarracho ni obra de arte". V. CARNOTA, WALTER F., *Constitución...*, ob.cit., p. 25.

(31) Un ejemplo al respecto lo brinda nuestro derecho público provincial, adicto a la alta resonancia declamatoria.

c) Enfoques

Finalmente, y no por ello menos importante, consignamos a los *enfoques*. Estos son los puntos de vista, ópticas, ángulos, perspectivas o visiones con que el constitucionalista aborda y se aproxima a tal o cual temática.

No es lo mismo, v.gr., estudiar la institución presidencial argentina desde un enfoque *histórico* (su tono caudillista, la incidencia del pensamiento alberdiano, los antecedentes norteamericanos de 1787 y chileno de 1833), que desde uno estrictamente *normativo* (el haz de competencias del art. 99 C.N.) o uno de cariz *filosófico-político* (¿está bien que el presidente no se someta al juego de responsabilidad política, a la inversa de lo que acontece con muchos titulares de ejecutivos europeos bajo un sistema parlamentario), o uno *comparativo* (¿tiene más atribuciones el presidente argentino, que sus pares de los Estados Unidos, Francia, Rusia o Sudáfrica?).

9. RELACIONES CON OTRAS DISCIPLINAS

Son múltiples las relaciones que entabla el derecho constitucional, con otras ramas del conocimiento científico:

a) Con la ciencia política

Como hemos visto al inicio de este capítulo, al hablar de derecho constitucional empezamos con el dato —político y jurídico— del estado como comunidad organizada.

Durante el s. XX, hubo intentos de acercar —y hasta de fusionar— ambas disciplinas, en una síntesis que algunos apodaron "ciencia político-constitucional" (32).

Sin renegar de proximidades y de estrechas vinculaciones entre las dos, Bidart Campos, en una pequeña obra especialmente dedicada a este tópico (33), concluyó en que ambas ciencias comparten el mismo objeto material (el estado o el régimen político), pero diverso objeto formal (el derecho constitucional brinda el encuadre jurídico del fenómeno político).

b) Con otras ciencias de la conducta (sociología, psicología social, antropología)

Aquellas escuelas que empujan al derecho constitucional al radio de acción de la ciencia política, hacen lo propio con otras disciplinas de la conduc-

(32) LINARES QUINTANA, SEGUNDO V., *Derecho constitucional e instituciones...*, ob., t. y p. cit. en nota 28.

(33) BIDART CAMPOS, GERMÁN J., *Ciencia política y ciencia del derecho constitucional: unidad o dualidad?*, Buenos Aires, 1982.

ta humana, como la sociología o teoría de la sociedad, la psicología social y la antropología.

Linares Quintana, al bucear dentro de la escuela del "conductismo político" (34), se ubica en esta orientación.

No hay dudas tampoco, desde una tesis filosófica que prioriza al sustrato de conductas contenidas en el llamado *mundo jurídico*, que hay fluido contacto entre el derecho constitucional y las ciencias de la conducta. Baste para ello evocar el tema de la *vigencia*, o de las *mutaciones constitucionales*, o de la *fuerza normativa de la constitución*, o de las fuerzas políticas que operan sobre el aparato gubernamental.

Por lo demás, no debe olvidarse que la constitución es ante todo *obra cultural* (35). Detrás de las constituciones documentales, hay un plexo de ideas, creencias, principios y valores que las vertebran, sustentan e imprimen sentido.

Las más de las veces, esas nociones fundacionales del régimen político se han volcado en los preámbulos y en los primeros artículos del texto (p. ej. "Título Preliminar" de la Constitución española de 1978).

c) Con la economía

Sin postular una dependencia absurda, no debe desdeñarse el aporte que la ciencia económica puede hacer al derecho constitucional.

Hay autores que han pretendido explicar *procesos constitucionales a partir del dato económico*, como Charles Beard respecto de la independencia de los Estados Unidos (36).

Otros escritores han apuntalado, desde una base económica, al edificio constitucional, como Juan Bautista Alberdi, con su *Sistema Económico y Rentístico*.

d) Con la historia

Los procesos históricos sirven para entender en parte el presente constitucional. El preámbulo de la Constitución argentina habla del "cumplimiento de

pactos preexistentes", y su factura responde en parte al modelo histórico-tradicional, en la clásica tipología de Manuel García Pelayo que ya estudiamos (37).

Cabe agregar que no debe predicarse una dependencia absoluta de la historia constitucional, tal como postula en los Estados Unidos, la escuela de la "intención originaria de los padres fundadores", que propicia "leer" la Constitución de Filadelfia de 1787 en el contexto de la época de sus autores. Una Constitución está destinada a servir al momento actual y al porvenir. Las generaciones actuales y las futuras son sus protagonistas principales. Ello no impide atender a las enseñanzas de la historia que, como se sabe, muchas veces tiende a repetirse.

(34) LINARES QUINTANA, SEGUNDO V., *Derecho constitucional e instituciones*, ob. y t. cit., p. 304.

(35) CARNOTA, WALTER F., *Reflexiones acerca del carácter incompleto de las constituciones*, ED, 127-733; HABERLE, PETER, *El Estado Constitucional*, México, 2003, p. 2, entre varias de sus obras.

(36) BEARD, CHARLES, *An economic interpretation of the Constitution of the United States*, New York, 1913. En las últimas décadas, se ha dedicado una porción de los textos constitucionales al tratamiento de su "constitución económica". Sobre esta noción, ver BIDART CAMPOS, GERMÁN J. y CARNOTA, WALTER F., *Derecho Constitucional Comparado*, Buenos Aires, 2000, t. II, p. 257; CARNOTA, WALTER F., *Instituciones de Derecho Público*, Buenos Aires, 2005, p. 65.

(37) BIDART CAMPOS, GERMÁN J., *Historia e ideología de la Constitución argentina*, Buenos Aires, 1969, p. 136.

CAPITULO II.1

LA ENSEÑANZA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES COMO PARTE DEL DERECHO CONSTITUCIONAL

SUMARIO: 1. Introducción. — 2. Proceso de sedimentación. — 3. Nuevos retos. — 4. Más desafíos. — 5. Conclusiones.

1. INTRODUCCIÓN

La enseñanza de los derechos fundamentales en las diversas Universidades Argentinas ha estado enmarcada en las vicisitudes y avatares políticos que signaron nuestra historia reciente (1), tal como no podía ser de otra manera, dado una materia de alta voltalidad y connotación política.

Clásicamente, el planteo de su transmisión y divulgación no variaba demasiado del que se efectuaba al entrenar al estudiantado sobre cualquier otra disciplina jurídica. Dicho en términos más técnicos, hasta la restauración de la democracia operada en 1983, los derechos no tenían *especificidad* en las currículas de las respectivas Escuelas de Derecho, no habiéndose producido todavía la plena recepción del fenómeno que venía aconteciendo en el campo del derecho internacional público, desde 1948 en adelante.

Es así que la orientación prevalentemente positivista de cuño normativo que marcó la enseñanza del Derecho durante gran parte del siglo XX, dominaba también a la hora de analizar a los derechos públicos subjetivos. Poco y nada se hizo en el campo de la multidisciplina o de la interdisciplina en el abordaje de estos temas.

Cabe destacar que dicho enfoque, muy parcial e insuficiente por cierto, era funcional a las bruscas oscilaciones que registraba nuestra deprimida institucionalidad. En efecto, aún en épocas de "gobiernos de facto", se enseñaba la litania de derechos que, pese a su consagración en la Constitución docu-

(1) CARNOTA, WALTER F., "La enseñanza de los derechos fundamentales desde la perspectiva integradora del Derecho Constitucional", en www.eldial.com, DC1E7.

mental de 1953-1960, distaban mucho de tener anclaje en la realidad, deviniendo en una mera abstracción.

A partir del reinicio del ciclo democrático de 1983, se cae en la cuenta de que algo había fallado en la materia. Las considerables violaciones a los derechos perpetradas por los gobiernos militares de 1976-1983 convencieron —tal como había ocurrido en la Europa de la segunda post-guerra— que no bastaba la repetición memorística y fuera de contexto de una “parte dogmática” constitucional, quimérica y lejana de la praxis política cotidiana. También se convino en que la protección puramente doméstica del espectro de derecho se había revelado insuficiente.

El auge de la expresión “derechos humanos” —a las que, mal que les pese a muchos, había ayudado la Administración Carter de los Estados Unidos, que tuvo como punto focal local la actuación de la CONADEP y el juicio a las Juntas Militares— generó en los claustros universitarios la necesidad de profundizar los estudios en esta área del ordenamiento jurídico.

Se ha dicho alguna vez con justeza que “las grandes frustraciones engendran grandes vocaciones”. Pues bien, el gran fracaso de los derechos escritos y no cumplidos en la época militar hizo que florecieran posteriormente, ya en el período de transición y consolidación democráticas, las reflexiones académicas sobre esta materia.

2. PROCESO DE SEDIMENTACIÓN

Se dijo más arriba que la transición democrática gatilló en nuestro medio a los estudios sobre derechos humanos.

En efecto, con la reforma del plan de enseñanza de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, encarado en el año 1985, las autoridades de ese entonces decidieron incluir —dentro del primer tramo de la Carrera, llamado “Ciclo Profesional Común— una asignatura bajo la denominación puntual de “Derechos Humanos y Garantías”. Con el tiempo, muchas Casas de Altos Estudios jurídicos —tanto estatales como privadas— reafirmarían dicha tendencia, copiando esta loable iniciativa.

Debe resaltarse que, en lo que respecta a la Facultad de Derecho porteña, el dictado de la nueva materia comenzó en el primer cuatrimestre de 1986.

Empero, hacia comienzos de 1987, los directivos de esa unidad académica se persuadieron de que la asignatura en cuestión no exhibía un perfil o identidad propios, o con mayor precisión, de que *había que formar suficientes docentes para abastecer las crecientes necesidades*.

Así, bajo el decanato del Profesor Jorge Alberto Sáenz, y la dirección departamental de la Profesora María Graciela Reiriz, se montó una experiencia única en su tipo, consistente en habilitar un Curso específico de capacitación para el cuerpo docente (“Curso Intensivo de Especialización en Derechos

Humanos”), bajo la coordinación del Profesor Eduardo Rabossi, quien para la época también se desempeñaba como Subsecretario de Derechos Humanos de la Nación.

Cabe destacar el éxito de esa iniciativa, que implicó que para el segundo cuatrimestre de 1987, la máxima Facultad de Derecho del país contase con cuadros versados en la peculiar problemática abordada.

Había, entonces, plena conciencia de que los derechos fundamentales no eran neutros, o que su enseñanza distaba mucho de ser aseptica. Corresponde subrayar, por lo demás, el clima de pluralismo y de respeto intelectual allí imperantes.

Convivieron, en esos primeros años de gestación y desarrollo, diversos enfoques: el constitucional, el científico-político, el administrativo, el internacional, el iusfilosófico, el penal, etc.

En 1988 se produjeron dos novedades trascendentes en la Facultad porteña en relación al tema:

1. La designación de dos Profesores Titulares interinos específicos de la materia (más allá de los anteriores Profesores coordinadores), nombramientos que recayeron en dos juristas de nota cuya formación en derechos humanos era insospechada y plural: el mencionado Rabossi y Germán J. Bidart Campos, quien dejaba su vieja cátedra de Derecho Constitucional en favor de Miguel Angel Ekmekdjian, quien había ganado el concurso respectivo;
2. La aprobación de los nuevos contenidos mínimos de la asignatura.

Dichos contenidos recogieron la tremenda interacción académica que se había producido en el Curso formativo de Rabossi mencionado más arriba.

Concretamente, las pautas que señalaban giraban en torno a cuatro ejes temáticos básicos:

- a) una teoría de los derechos humanos,
- b) su historia,
- c) su recepción positiva tanto interna cuanto internacional,
- d) su realidad sociológica.

Paralelamente, en el país se sucedían luces y sombras en el terreno de los derechos fundamentales. La Corte Suprema de Justicia exhibía un sano activismo judicial, representado por una serie de decisiones proclives al fortalecimiento de los derechos subjetivos, como en materia de intimidad, libertad de prensa, matrimonio civil y servicio militar obligatorio, entre muchas otras (2).

(2) BIANCHI, ALBERTO, *Una Corte liberal (la Corte de Alfonsín)*, Buenos Aires, 2007.

Sin embargo, a la par que se incrementó notablemente el material normativo interno sobre estos asuntos, se dictaron leyes que muchos sectores consideraron regresivas.

La bibliografía existente aumentó también considerablemente, con obras de gran calidad y muy útil consulta.

3. NUEVOS RETOS

El cambio de Administración que aconteció en 1989 abrió nuevos frentes en la discusión sobre los derechos humanos.

Daba la impresión de que los clásicos derechos civiles y políticos —v.gr., los anidados en los arts. 14, 16, 17, 18 y 19 de la C.N.— aparecían sin mayores cuestionamientos en el horizonte político-jurídico.

Pero el debate más fuerte, que se daría a lo largo de toda la década de los noventa, se concentraría en el frente de los derechos económicos y sociales.

Es que el modelo de ajuste estructural que se empieza a perfilar desde 1991 en toda América Latina (y Argentina no va a ser la excepción) tiene como lógica consecuencia una fuerte impugnación de las apuntadas categorías. La ampliación del más Alto Tribunal daría con el tiempo confirmación al precitado modelo.

La enseñanza de los derechos humanos, empero, fue orientándose hacia el campo internacional. Gravitó de alguna manera la nueva conformación del Alto Tribunal. Ahora, la Corte no era la última instancia, sino que cabían las instancias supranacionales de protección, como la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Un notorio intento de armonización y de conciliación entre las esferas doméstica o interna e internacional lo conformó, a nuestro criterio, la vasta reforma constitucional emprendida en 1994.

No sólo la apuntada revisión fue la más consensuada y democrática de las habidas entre nosotros, sin proscripciones y con la representación de la totalidad del arco político, sino que introdujo grandes cambios al edificio constitucional.

Una de esas transformaciones fue la "constitucionalización del derecho internacional público". En efecto, hasta allí el "corpus" del derecho internacional acusaba diversos grados de vigencia, con enorme resistencia en su aplicación por parte de los tribunales internos.

A partir de allí, y sobre la construcción que realiza el art. 75 inc. 22, no va a poder alegarse una inicial antinomia o contradicción entre ambos ordenamientos. Tan es así que la nota de "complementariedad", sobre la cual venía bregando Bidart Campos durante años, fue receptada de manera explícita en la norma constitucional apuntada.

Pero algunos académicos y científicos del derecho descodificaron parcialmente el mensaje del constituyente reformador. Lejos de integrar el derecho internacional al plexo constitucional como había sido su diáfana voluntad, montaron obras de doctrina, programas de estudio y cátedras universitarias en diversos establecimientos ocupándose —tal como en ciertos casos de la Europa de post-guerra— de la arista internacional, en detrimento de las consideraciones nacionales más elementales.

Dicha tendencia se vino a reforzar con el diagnóstico globalizador. Muchos han querido ver —con razón— al lado de la globalización económica, una de índole jurídica.

Pero ello no debe significar descartar por completo en el análisis al estado nacional, su vigencia como realidad política y menos descartar del panorama de los derechos fundamentales nada menos que a la Ley Suprema, que es donde encuentran cimiento y reconocimiento.

Cabe hacer notar que la Constitución reformada ha habilitado nuevas fuentes, como los tratados constitucionales y los supra-legales. Pero ello no implica que ellos tengan en nuestro ordenamiento "valor supraconstitucional".

Empero, la tendencia universitaria en la materia continuó confiriendo prioridad a la perspectiva internacional, quizás potenciada por la apuntada revisión constitucional.

Ello ha sido motivo de constante debate académico. Así, en el año 1998, y como producto de una iniciativa llevada a cabo por el entonces "Instituto de Investigaciones del Nuevo Estado" de la Universidad de Belgrano, dirigido por Jorge R. A. Vanossi, se realizó un Seminario Internacional sobre la enseñanza del derecho constitucional.

De la síntesis del mismo, publicada en el Boletín Informativo de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, núm. 153, enero de 1999, p. 7, se desprende que la participación del recordado Maestro Carlos Colautti y de Walter F. Carnota "...estuvo motivada en el actual debate acerca de los contenidos mínimos y planes de estudio. El caso es que, en teoría, Elementos de Derecho Constitucional debería tratar la parte orgánica en tanto que la parte dogmática sería propia de otra materia: Derechos Humanos y Garantías, pero que sin embargo esto generalmente no sucede porque sus contenidos incluyen también elementos de Filosofía del Derecho y de Derecho Internacional Público, siendo que son los profesores de esa última orientación los que predominan..."

La división del Departamento de Derecho Público ordenada por el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la U.B.A. en julio de 1999, que dispuso que el derecho constitucional pasara a la órbita del nuevo Departamento de Derecho Público I, y derechos humanos al de Derecho Público II, tornó muy complicado el diálogo entre ambos sectores docentes. La reforma del plan de estudios de la carrera de Abogacía no ha encontrado hasta el presente algún grado de articulación en este punto.

El cuadro de situación en otras Casas acusa diferencias. Así, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora durante años existió diversidad de enfoques en el abordaje de los derechos humanos, lo cual se vio reforzada con la instalación de dos nuevas cátedras hacia agosto de 2002.

Por el contrario, en varias universidades privadas se ha vinculado el estudio de los derechos humanos al de la escuela filosófica dominante en ese instituto de enseñanza (pensamiento de autores tan disímiles como Santo Tomás de Aquino y sus continuadores—Universidad Austral—o Carlos Santiago Nino—Universidad de Palermo—, por ejemplo, etc.).

4. MÁS DESAFÍOS

Varios autores han venido destacando lo que había enseñado la Conferencia de Viena de 1993: que los derechos son interdependientes, sin que se pueda válidamente sostener la subsistencia de las clásicas libertades civiles y políticas desconociendo las categorías de los derechos de índole prestacional, o "welfare rights".

Algunos pronunciamientos de la nueva Corte Suprema parecen insistir en esta cuestión: "Vizzoti" (3) y "Aquino" (4) son ejemplos de ello. Mientras tanto, sigue el debate en materia penal, abierto por los casos "Arancibia Clavel" (5) y "Simón" (6).

Nótese que el sector de derecho penal ha venido ocupándose mucho de la cuestión de referencia, como por ejemplo en materia de condiciones de los establecimientos penitenciarios (7).

5. CONCLUSIONES

Hemos llegado a una serie de conclusiones, fruto de la reflexión precedente y de la experiencia académica al respecto:

1. De cara a procesos de reformas de planes de estudio en las universidades nacionales, se deberá repensar la adecuada articulación entre las asignaturas "derechos humanos" y "derecho constitucional", para que no se extravíe la riqueza temática de la parte dogmática de la Constitución Nacional;

2. Se deberá tener bien presente que el orden internacional es, al decir de Bidart Campos, "mínimo y subsidiario", es decir, complementario y no fundante de la legalidad objetiva;
3. Deberá asimismo recordarse que la noción de derechos fundamentales es integral e interdependiente, tal como lo ha reclamado la Conferencia de Viena de 1993, y que todos esos derechos gozan de la misma fuerza operativa, impliquen para el Estado obligaciones positivas (prestaciones) o negativas;
4. Los derechos fundamentales no sólo tienen un origen jurídico-positivo, sino que está demostrado que las crisis más profundas por las que ha atravesado la Humanidad trascienden al legislador;
5. No es ejercicio inútil plantearse la fundamentación de los derechos, ya que es insito al ser humano indagar acerca del origen de los fenómenos.

(3) Fallos: 327:3677.

(4) Fallos: 327:3753.

(5) Fallos: 327:3312.

(6) Fallos: 328:2056.

(7) "Verbitsky", Fallos: 328:1146.

CAPITULO II.2

LA INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN COMO PROBLEMA

SUMARIO: 1. Introducción. — 2. Interpretar la Constitución e interpretar la ley. — 3. Interpretar y controlar la Constitución. — 4. El lenguaje constitucional: textura abierta, vaguedad y ambigüedad. — 5. Modelos de interpretación constitucional: a) Interpretación literal o semántica. b) Interpretación sistemática. c) Interpretación historicista. d) Interpretación dinámica. e) Interpretación teleológica o finalista. f) Interpretación previsor. — 6. La interpretación comparada, ¿es de utilidad? — 7. Rumbos de la tratadística constitucional.

1. INTRODUCCIÓN

La tarea más corriente y habitual del jurista es la de interpretar textos o materiales jurídicos. Así como el matemático trabaja con números, o el químico con fórmulas, el científico del derecho debe vérselas con el significado de los términos empleados por el autor de las normas; recién allí entonces podrá extraer la consecuencia jurídica debida a determinada conducta prevista de antemano.

En derecho, siempre se interpreta. Hay un mito medieval que los textos diáfanos no requieren interpretación: *in claris non fit interpretatio* (1). Sin embargo, una norma, por más sencilla que parezca, siempre requerirá de la operación de la interpretación.

Sintéticamente, interpretar implica desentrañar el significado de una regla jurídica, que como veremos a continuación se complica cuando de la Constitución se trata.

2. INTERPRETAR LA CONSTITUCIÓN E INTERPRETAR LA LEY

Cabe destacar que la temática de la interpretación no es exclusiva de la teoría constitucional, sino que es una problemática que hunde sus raíces en

(1) V. CARNOTA, WALTER F., *Curso de Derecho Constitucional*, Buenos Aires, 2001, p. 11; GARCÍA BELAUNDE, DOMINGO, *La Constitución y su dinámica*, Lima, 2006, p. 87.

la teoría general del derecho. Después de todo, se interpretan las normas, y la Constitución, aunque la más importante, es sólo un conjunto de reglas en el elenco más alto del ordenamiento normativo estatal.

Pero las propias características que vimos que singularizan al concepto de Constitución—su calidad fundamental, su naturaleza política y jurídica a la vez (2)—, hacen que la faena hermenéutica no sea en sede constitucional igual que en las demás áreas del derecho.

Ya prevenía John Marshall: "Una constitución, para contener un detalle exacto de todas las subdivisiones de los grandes poderes que admita, y de todos los medios por los cuales se podrían ejecutar, exigiría la prolijidad de un código legal, y escasamente podría ser abrazada por la mente humana. Nunca, probablemente, sería entendida por el público. Su naturaleza, entonces, requiere que sólo sus grandes lineamientos sean marcados, sus objetos importantes designados... Al considerar esta cuestión, entonces, nunca debemos olvidar que es una *Constitución* lo que estamos explicando" (3). Y largamente se discute hoy el rol de las Cortes Supremas y de los Tribunales Constitucionales en la específica función de la interpretación aplicativa de la Constitución.

El problema de la interpretación en el derecho es bastante añejo. Piénsese sino en las diversas elaboraciones que al respecto se hicieron en el campo del derecho civil a lo largo de todo el siglo XIX, sobre todo en Francia. Empero, la dimensión constitucional de la interpretación es relativamente reciente; es un producto que irrumpe hacia mediados del s. XX.

Centralmente, ello se debe a que el concepto de Constitución que hasta entonces predominaba en Europa era político, y se pensaba—erradamente—que las herramientas que se desplegaban en las demás ramas del derecho eran inútiles en este campo (4).

Recién luego de la afirmación de la *fuerza normativa de la Constitución*, es decir, del hecho incontrastable de que la Constitución es norma jurídica y que tiene su propio sector dentro del mundo jurídico (el derecho de la Constitución), es cuando la interpretación constitucional eclosiona como problema científico y práctico para el jurista.

(2) V. GARCÍA TOMA, VÍCTOR, *Teoría del Estado y Derecho Constitucional*, Lima, 2005, p. 495, quien puntualiza que los preceptos constitucionales "son normas indesligables y constituyentes de los hechos políticos y sociales".

(3) Corte Suprema de los Estados Unidos, "Mc Culloch v. Maryland" (1819).

(4) "Si el Parlamento es soberano y no hay límites jurídicos para su manifestación de voluntad, la Constitución sólo puede tener una *interpretación política*". V. PÉREZ ROYO, JAVIER, *Curso de Derecho Constitucional*, Madrid y Barcelona, 2005, p. 130. Se ha señalado que hay normas constitucionales incompletas, pero que "sin embargo, no por ello dejan de ser normas". V. FERNÁNDEZ SEGADO, FRANCISCO, "Reflexiones en torno a la interpretación de la Constitución", en FERRER MAC-GREGOR, EDUARDO (Coordinador), *Interpretación Constitucional*, tomo I, México, 2005, p. 502.

3. INTERPRETAR Y CONTROLAR LA CONSTITUCIÓN

Muy concatenado con el *control de constitucionalidad*, y como una subcategoría de la teoría de la constitución, se ubica la compleja problemática del epígrafe.

¿Qué significa interpretar un enunciado normativo constitucional? Implica ni más ni menos que atribuir, asignar o desentrañar significados. Se trata de una labor de descodificación, en cuanto se intenta averiguar qué quiso decir el legislador constitucional (originario o derivado).

La operación así descripta evoca la idea de una lectura *objetiva* del precepto de que se trate (en este caso, la Constitución, un tratado jerarquizado, una ley de contenido constitucional). Pero no debe desatenderse al aspecto *subjetivo* de la faena interpretativa, que pone el acento en quién es el que practica la interpretación.

En tal sentido, puede ser el legislador (lo que comúnmente se llama "interpretación auténtica") que a través de una norma posterior (sea aclaratoria, correctiva o común) precisa alguna faceta de una directiva dictada con anterioridad, la comunidad científica o sobre todo el juez, quien en nuestro sistema tiene a su cargo el control constitucional. Debe quedar en claro que para controlar la constitucionalidad de una regla jurídica, hay que previamente interpretarla.

Pero sería francamente un error pensar que la Constitución sólo es interpretada por órganos del poder. Aquí viene a cuento el concepto de "comunidad interpretativa", por la cual se comprometen en la empresa hermenéutica tanto los detentadores cuanto los destinatarios del poder.

En similar línea, Peter Häberle afirma: "Un examen realista del surgimiento de la interpretación puede requerir un concepto de interpretación más amplio, para el cual los ciudadanos y los grupos, los órganos del Estado y la opinión pública, son 'fuerzas productivas de la interpretación', es decir, intérpretes de la Constitución en sentido amplio" (5).

La estrecha conexión entre control e interpretación hace entonces que la misión hermenéutica sea muy distinta en este campo del ordenamiento, que en general en las demás áreas del derecho (lo que ya vimos como "*interpretación de la ley*"). Interpretar un artículo del código civil, o del penal, o del procesal, no conlleva el mismo valor, pues en principio la norma no corre el riesgo de ser inaplicada, ni las previsiones normativas son tan abiertas, o complejas, como las constitucionales.

Una primera distinción relevante es aquella que discrimina entre la *interpretación de la Constitución* de la *interpretación desde la Constitución*.

Ante la primera, lo que hacemos es determinar el significado y alcance de un precepto constitucional. El artículo 41 C.N. nos habla del derecho a un

(5) V. HÄBERLE, PETER, *El Estado Constitucional*, México, 2003, p.150.

"ambiente sano y equilibrado". La vaguedad de los conceptos empleados por el constituyente reformador obliga a extremar los esfuerzos interpretativos.

El segundo caso es distinto. La interpretación "desde la Constitución" presupone que el intérprete se coloca en un atalaya, sitio o mirador (el de la Constitución) desde cuya especial perspectiva juzga la compatibilidad del resto del sistema jurídico con la norma de base.

4. EL LENGUAJE CONSTITUCIONAL: TEXTURA ABIERTA, VAGUEDAD Y AMBIGÜEDAD

La materia prima de la interpretación es el lenguaje, ya que como bien definió Goldschmidt, "la interpretación consiste en comparar el sentido lingüístico de una norma, usual en el grupo al que se dirige, con la auténtica voluntad de su autor, inferida de indicios observables, y en caso de discrepancia en hacer valer la última por encima del primero" (6).

Fruto de su calidad de norma jurídica fundamental y de estatuto político a la vez, la Constitución presenta cláusulas sumamente abiertas, cuya estructura denota la voluntad de concitar adhesiones al proyecto común y dejar los pormenores y detalles al despliegue reglamentario del legislador ordinario.

El constitucionalismo clásico ha sido prodigo en expresiones notoriamente vagas, cargadas de un gran significado emotivo: "debido proceso adjetivo", "derecho de defensa", "república", "democracia", "igualdad", "libertad".

La reforma constitucional de 1994 (7) exhibe una marcada tendencia a las "cláusulas de textura abierta", con motivo del ceñido consenso que la generó. ¿Qué es, en concreto, propender a un "ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano (art. 41)? ¿Qué son las "medidas de acción positiva" contenidas en el art. 75, inc. 23 constitucional?

Frente a estas reglas tan abiertas, asume capital importancia el papel del legislador y del juez, a fin de lograr su cabal determinación conceptual.

Otras fórmulas del lenguaje constitucional son notoriamente ambiguas, es decir, se prestan a más de un significado posible. El ejemplo clásico que se suministra es el verbo "sostener" (8) que contiene el art. 2º de la Constitución al definir la relación entre el Estado y la Iglesia Católica. Para algunos, dicha cláusula hace referencia a una "unión moral" entre ambos, como propugna

(6) V. GOLDSCHMIDT, WERNER, "El análisis de casos como elemento imprescindible de la enseñanza jurídica", en "Academia (Revista sobre enseñanza del Derecho de Buenos Aires)", año 2, número 4, primavera de 2004, p. 128.

(7) V. CARNOTA, WALTER F., *Constitución de la Nación Argentina. Comentario General*, 2ª edición, Buenos Aires, 1998.

(8) V. GARGARELLA, ROBERTO, "Interpretación del Derecho", en AA.VV., *Derecho Constitucional*, Buenos Aires, 2004, p. 651.

Germán Bidart Campos. Otros autores piensan que sólo se trata de una previsión de índole presupuestaria con destino al culto católico.

Asimismo, otra expresión ambigua es el vocablo "acuerdo", ya que el mismo puede significar un convenio con otro Estado o la conformidad de un órgano del Estado (p.ej. Senado) a la propuesta que realiza otro (v. gr. el Presidente de la Nación, en el caso de los jueces, embajadores y oficiales de las fuerzas armadas).

En los últimos tiempos, se ha venido insistiendo con que el lenguaje jurídico en general es exageradamente rebuscado o barroco. Particularmente, se han colocado las críticas en un léxico forense demasiado alejado de la sociedad a la que está destinada a servir, desalentando su participación en los asuntos relativos a la impartición de justicia.

Es de hacer notar, sin embargo, que cada disciplina científica y que cada obrar humano tiene su jerga específica (la medicina, la ingeniería, y así sucesivamente), y no se puede desconocer por completo esos aportes.

Respecto del campo constitucional, se ha abogado por reglas o técnicas de elaboración que no generen textos demasiado complicados, o que dificulten su comprensión por el gran público, alejando a la Constitución de la sociedad.

5. MODELOS DE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL

a) Interpretación literal o semántica

Una primera aproximación dentro de la teoría de la interpretación sugiere examinar la literalidad o gramaticalidad de los vocablos utilizados por el legislador constitucional, para así estar en condiciones de determinar el sentido atribuible a la norma. Aquí lo que se interpreta son en definitiva *las palabras usadas por el texto constitucional*.

Hablar de este tipo de interpretación, más allá de su atractivo elemental inicial, no implica reducir la trascendencia de la tarea a emprender, puesto que el significado a desentrañar no es el puramente gramatical sino las implicaciones *jurídicas* de la norma.

Por lo demás, puede ocurrir que el documento utilice expresiones vagas o ambiguas, y cuya denotación vaya cambiando con el contexto histórico.

b) Interpretación sistemática

Continúa con el estudio de los vocablos, pero intenta compaginarlos dentro de un *sistema* o un todo coherente de normas. También se la ha llamado interpretación armonizante o conciliadora, y ha sido empleada reiteradamente por la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia, desde los inicios mismos de su actuación (Fallos: 1:300).